

제10장 | 외국인의 상속등기

제 1 절 | 총 설

국제화·세계화 시대에 걸맞게 국제교류의 증가로 인해 외국에 거주하는 재외동포(외국국적 동포 포함)는 700만명에 육박하고 있다. 재외동포가 증가함에 따라 이들이 소유하고 있는 국내의 부동산에 관한 법률관계도 상당히 복잡하게 전개된다. 특히 일방 당사자 또는 쌍방 모두가 외국인인 경우에 이들 소유의 부동산에 관한 국제적 거래가 증가하고 있고, 또한 이들이 우리나라에 부동산을 남기고 사망하여 그 배우자나 자(子)가 이를 상속하는 등의 법률관계가 점차 증가하고 있다.

우리 민법은 외국인이 상속인이 되는 경우에도 한국인이 상속인이 되는 경우와 아무런 차별을 두고 있지 않다. 외국인이 한국에 거주하는지 여부도 상관이 없다.

외국인의 상속등기는 등기신청인과 관계인의 일부 또는 전부가 외국인인 경우를 말한다. 이 등기절차는 통상의 상속등기절차와는 다른 특성이 있고, 외국인이 국내 부동산을 취득하는 경우 일정한 법률상의 제약을 받을 수도 있으므로, 상속등기를 함에 있어서 국제사법에 따라 상속의 준거법을 결정해야 할 필요성이 있다.

이하에서는 먼저 이러한 외국인이 포함된 상속등기에 있어 상속의 준거법에 대하여 살펴보고, 외국인의 상속등기절차에 대해서 신청정보와 첨부정보를 중심으로 설명하기로 한다.

제 2 절 | 상속의 준거법

1. 상속의 준거법 결정

상속제도는 신분관계뿐만 아니라 재산의 이전이라는 이중적 성격을 갖고 있어 상속의 준거법을 결정하는 방식 또한 이를 반영하고 있다. 즉 상속의 준거법에 관하여는 ① 상속통일주의와 ② 상속분할주의가 있다.

상속통일주의란 모든 피상속인의 재산은 동산이나 부동산의 구별 없이 피상속인의 속인법에 의하여 상속의 준거법을 결정해야 한다는 입장이다. 즉 상속재산의 소재지를 불문하고 전 상속재산에 대하여 통일적으로 하나의 법률질서에 따라 지배되어야 한다는 것이다. 상속통일주의는 상속의 신분관계 측면을 강조한 것으로 피상속인의 보호가 강조되고 있어 상속재산의 소재지와 관계없이 통일적으로 속인법을 적용할 수 있어 그 적용이 용이하고 명확하여 적용상 실효성이 크다는 장점이 있으나, 재산소재지의 국제사법이 분할주의를 채택하고 있는 경우에는 속인법상의 상속은 실효성을 거두기 어렵다는 단점이 있다.

상속분할주의란 상속을 부동산상속과 동산상속으로 구별하여 부동산의 상속은 그 부동산의 소재지법에 따르고, 동산의 상속은 상속인의 소재지법 또는 본국법에 따라 상속의 준거법을 결정하여야 한다는 입장이다. 이 입장은 재산관계의 측면을 강조한 것으로 재산소재지에서 공익보호란 측면에서 타당하다는 장점이 있으나, 동산이나 부동산의 소재지가 변할 때마다 그 준거법이 달라지기 때문에 상속관계의 처리가 복잡해진다는 단점이 있다.

상속통일주의는 다시 속인법주의로서의 본국법주의와 주소지법주의로 구별되는바, 이탈리아·독일·네덜란드·스페인·스웨덴·폴란드·일본·중국 등이 본국법주의를 택하고 있고, 노르웨이·덴마크·중남미 국가 등이 주소지법주의를 택하고 있다.

상속분할주의는 미국·영국 등의 영미법계 국가와 프랑스·벨기에·헝가리·룩셈부르크·루마니아·러시아·터키 등에서 채택하고 있다.

최근에는 이러한 상속통일주의와 상속분할주의를 단일원칙으로 채택함으로 인한 문제점을 해결하기 위하여 양 주의의 대립을 지양하고 제한된 범위 내에서 당사자 자치의 원칙을 도입하고 있는 입법례(재산상속의 준거법에 관한 헤이그협약 및 독일·스위스·이탈리아 등)도 있다.

2. 우리나라의 상속준거법

우리 국제사법은 제7장 상속에서 상속 및 유언의 준거법을 규정하고 있다. 국제사법 제49조제1항은 “상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 의한다.”고 하여 원칙적으로 피상속인의 본국법주의를 채택하고 있다. 다만 상속준거법의 단일 원칙으로 인한 문제점을 해결하기 위하여 제한된 범위 내에서 당사자 자치의 원칙을 도입하였다. 즉 피상속인은 유언으로 준거법 선택 시에 존재하는 자신의 상거소지법을 선택할 수 있으며(같은 법 제49조제2항제1호), 부동산 상속의 경우에는 피상속인으로 하여금 그 소재지법을 선택할 수 있도록 규정하고 있다(같은 법 제49조제2항제2호). 이러한 준거법 선택은 피상속인이 생활의 근거지로 되어 온 곳의 법을 적용받고자 하는 소

망과 필요에 부응하도록 한 것이다. 다만 사망 시에도 피상속인의 상거소는 그곳에 유지되어야 한다. 또한, 부동산의 소재지법을 선택한 이유는 상속과 부부재산제 및 물권의 준거법이 일치될 수 있어 이들 관계에서 발생하는 복잡한 법률문제를 회피할 수 있고 실효적이고 신속한 유산채무를 해결할 수 있도록 하기 위한 것이다.

우리 국제사법은 준거법 지정의 명확성을 기하기 위하여 그 방식은 유언에 적용되는 방식에 따라 명시적으로 지정하도록 하고 있다(같은 법 제49조제2항 본문). 따라서 피상속인이 위와 같은 선택을 하는 경우에는 상속의 준거법이 피상속인의 본국법이 아니라 피상속인의 상거소지법 또는 부동산소재지법이 적용된다.

3. 상속준거법의 적용범위

가. 상속의 개시

상속의 준거법은 상속개시의 원인, 시기, 장소, 상속재산에 관한 비용 등에도 적용된다. 예를 들어 실종선고가 상속개시의 원인으로 되는가의 문제도 상속의 준거법에 따른다.

따라서 국제사법 제12조(실종선고)에 의하여 외국인이 우리나라 법원에서 실종선고를 받을 경우에는 그 본국법의 내용 여하에 불구 하고 우리나라에 있는 재산에 관한 한 상속의 개시여부 및 그 시기는 우리나라법에 의한다.

또한, 상속회복청구권에 관한 문제로 상속회복청구의 당사자, 상속회복청구권의 효력 등은 상속의 준거법에 따른다.

나. 상속인

상속의 준거법은 상속인의 범위, 상속인의 순위, 상속인의 상속능력, 상속결격사유 등의 문제에도 적용된다고 할 것이다. 따라서 태아가 상속능력을 갖는가의 문제는 상속의 준거법인 피상속인의 본국법에 따른다.

그러나 상속인이 되기 위한 전제로 되는 피상속인과의 혼인관계, 친자관계, 친족관계의 존부는 이른바 선결문제로서 별개의 준거법 지배를 받아야 할 것이다.

다. 상속재산

상속재산에 관하여 그 구성 및 이전의 문제는 상속의 준거법에 의한다. 즉 피상속인의 어떤 재산이 상속재산을 구성하는지 여부, 상속재산이 어떤 과정을 거쳐서 상속인에게 이전하는지 여부(상속재산이 상속의 개시와 함께 직접적으로 상속인에게 이전되는지, 대표자에 의한 관리·청산을 거쳐서 비로소 상속인에게 이전하는가의 문제)는 상속의 준거법에 의한다.

또한, 상속재산의 분할시기, 방법, 기준, 효과 등은 상속의 준거법에 의한다.

라. 상속분 및 유류분 등

상속의 준거법은 상속분, 유류분, 기여분에 관한 문제에도 적용된다. 즉 상속재산 중 관념적·분량적인 일부를 말하는 상속분, 공동상속인 중에 피상속인의 재산의 유지 또는 증가에 관하여 특별히 기여하였거나 피상속인을 특별히 부양한 자가 있을 경우에 이를 상속분에 고려하는 기여분제도 및 상속이 개시됨과 동시에 일정한 범위의 상속인이 피상속인의 재산의 일정한 비율을 확보할 수 있는 유류

분 제도 등에 관한 문제도 상속의 준거법에 따른다.

마. 상속의 승인 및 포기

상속인이 단순승인, 한정승인 및 포기를 할 수 있는가의 문제도 상속의 준거법에 의한다. 다만 피상속인의 본국법상 포기가 인정되지 않고 상속인의 본국법상 이것이 인정되는 경우에는 포기할 수 있는지가 문제 된다. 그러나 상속의 문제는 오로지 상속의 준거법인 피상속인의 본국법에 의해야 하고 피상속인의 본국법이 포기를 인정하지 않는 이상 상속인의 본국법의 내용 여하에도 포기를 인정하지 않는다고 보는 것이 타당할 것이다.

국제사법상 법률행위의 방식은 그 행위의 효력을 정한 법에 의하므로(국제사법 제17조제1항) 상속포기의 방식은 상속의 준거법인 피상속인의 본국법에 의하여야 하나, 행위지법에 의하여 한 법률행위의 방식도 이를 유효로 하고 있다(같은 법 제17조제2항). 따라서 상속인이 행위지법에 의해 상속포기를 하였다면 이를 유효한 것으로 보아야 한다(선례 6-225).

바. 상속인의 부존재

피상속인의 사망으로 상속이 개시되었으나 상속인이 없는 경우 상속재산은 국고 또는 공공단체에 귀속하는 것이 각국의 법제상 일반적으로 인정하고 있다.

그런데 이러한 재산귀속의 성질에 관하여는 견해가 나누어져 국고 또는 그 밖의 공공단체가 최종의 법정상속인으로서 유산을 취득한다고 하는 상속권주의(독일, 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 스위스 등)와 영토권의 작용에 의해 선점하는 것이라고 하는 선점권주의(영국, 미국,

라틴아메리카 각국, 오스트리아 등)가 있다.

이와 같은 문제는 당해 준거법을 어디에서 구할 것인가의 문제로써 법률관계 성질결정의 문제에 귀착된다고 할 것이다. 우리 국제사법 제49조에서 말하는 “상속”이란 친족관계를 중심으로 하는 재산의 승계관계라는 의미로 해석되고, 상속인부존재의 경우에 관한 국고 또는 공공단체에 의한 상속재산취득의 관계에는 동조의 적용이 없다고 해석된다.

그러므로 이 문제는 상속인의 확정이라는 문제로 보지 않고 무주(無主)의 재산처리문제로서 이 준거법은 재산의 소재지법에서 구해야 할 것으로 생각된다. 따라서 외국인이 한국에 재산을 남기고 사망하고 그 본국법에 의하면 상속인이 존재하지 않는 경우에는 재산소재지법인 우리나라법에 의해 그 재산도 우리 국고에 귀속하는 것이 된다.

또한, 한국인이 외국에 재산을 남기고 사망하고 우리나라법에 의해 상속인이 존재하지 않을 경우에는 재산소재지법인 외국법에 따라서 재산의 귀속이 결정되고 보통은 소재지국의 국고에 귀속된다고 할 것이다.

사. 유언의 집행

상속에 관한 사항을 내용으로 하는 유언의 집행은 상속의 문제로서 상속의 준거법에 의한다. 따라서 유언집행자의 지정, 선임 및 권한은 상속의 준거법인 피상속인의 본국법에 따른다고 할 것이다.

4. 상속준거법의 관련사항

가. 반 정

반정(反定)이란 외국적 요소가 있는 법률관계에 대하여 법정지(내국법)의 국제사법이 어느 외국법을 적용할 것을 지정하고 있으나, 그 외국의 국제사법에 의하면 법정지법 또는 제3국법을 적용할 것을 규정하고 있는 경우에 그 규정에 따라 법정지법 또는 제3국법의 적용을 인정하는 것을 말한다.

우리 국제사법 제9조는 준거법 지정시의 반정에 대하여 규정하고 있는바, 제1항에서는 “이 법에 의하여 외국법이 준거법으로 지정된 경우에 그 국가의 법에 의하여 대한민국 법이 적용되어야 하는 때에는 대한민국의 법(준거법의 지정에 관한 법규를 제외한다)에 의한다.”고 하여 반정의 원칙을 명문으로 인정하고 있다.

영국인이 한국에 부동산을 남기고 사망한 경우에 우리 국제사법 제9조의 규정에 따라 영국법에 준거하여야 하나, 영국법에 의하면 상속에 관한 국제사법의 원칙으로 부동산물권에 있어서는 소재지법에 따르도록 되어 있어 피상속인의 유산인 부동산도 소재지법인 우리 민법을 적용하게 된다.

나. 사회질서에 반하는 외국법

상속에 있어 피상속인의 본국법 규정이 우리나라의 사회질서에 위반하는 경우에는 그 외국법의 적용이 배제된다. 사회질서에 반하는 외국법의 적용문제에 관하여 우리 국제사법 제10조(사회질서에 반하는 외국법의 규정)는 “외국법에 의하여야 하는 경우에 그 규정의 적용이 대한민국의 선량한 풍속 그 밖의 사회질서에 명백히 위반되는 때에는 이를 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있다.

우리 국제사법상 공서의 원칙은 그 적용결과로 인해 자국의 기본

적인 사회질서가 파괴될 우려가 있는 경우를 막기 위한 것이다.

또한, 어떤 법률관계에 적용되어야 할 외국법은 결정되었지만 그 내용이 불명확한 경우가 있다. 이 같은 경우에는 우리나라 법질서 전체의 견지에서 조리에 의하여야 할 것이다.

다. 국적(이중국적, 무국적)

상속에 관하여 국적문제는 크게 이중국적(국적의 적극적 저촉)과 무국적(국적의 소극적 저촉)으로 나누어 볼 수 있다.

먼저 이중국적에 관하여 살펴보면, 출생·혼인·이민 등으로 이중국적이 성립하는 경우 어느 국적을 가지고 당사자에게 적용할 본국법을 결정하느냐가 문제가 된다. 우리 국제사법은 상속이 피상속인의 본국법에 의하여야 하는 경우에 당사자가 둘 이상의 국적을 가지는 때에는 그와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 그 본국법으로 정한다(국제사법 제3조제1항 본문). 다만 그 국적 중 하나가 대한민국의 때에는 대한민국 법을 본국법으로 한다(같은 법 제3조제1항 단서).

그러나 외국인이 이중국적자인지 아닌지를 어떻게 인정하는가는 문제는 있을 것이다. 피상속인이 이중국적자인지 아닌지의 여부는 하나의 국적증명서 예를 들어 하나의 여권만이 제출된 경우에 그 사람의 본국법은 그 여권에 의하여 규정되게 된다. 또한, 외국인등록증명서 등에 국적이 하나밖에 기재되지 않은 경우도 이와 같을 것이다.

여권 등에 의하여 이중국적인 것이 명확할 때에는 그 국적취득의 선후에 의하여 그 판단을 하게 된다. 그러나 그 복수의 외국국적이 동시에 취득된 경우라면 본국법의 결정이 문제가 될 것이다.

이중국적이 성립하는 경우 어느 국적을 가지고 당사자에게 적용할 본국법을 결정할지에 관하여 개정 전涉外사법은 신국적을 우선시키고 있었으나, 개정된 국제사법은 무조건 최후의 국적을 우선하지는 않고 당사자의 연결점 관계를 고려하여 “당사자와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법”을 우선 시키도록 하였다(같은 법 제3조제1항 본문). 이는 독일, 스위스, 일본 등의 입법례가 취하고 있는 입장이기도 하다.

다만 이중국적 중 하나가 대한민국인 때에는 개정 전 법률과 마찬가지로 대한민국법을 본국법으로 하도록 하여 내국 국적 우선의 원칙을 고수하였다(같은 법 제3조제1항 단서).

다음으로 무국적에 관하여 살펴보면, 우리 국제사법은 당사자가 국적을 가지지 아니하거나 당사자의 국적을 알 수 없는 때에는 그의 상거소(常居所)가 있는 국가의 법에 의하고, 상거소를 알 수 없는 때에는 그의 거소가 있는 국가의 법에 의한다(같은 법 제3조제2항).

국적이 없으면 이에 대신할 연결점이 있어야 당사자의 본국법을 정할 수 있다. 무국적자에 대하여는 주소(주소가 없으면 거소)로서 국적에 대신하게 하는 것이 일반적으로 인정되어 왔으나(구涉外사법 제2조제2항), 개정된 국제사법은 당사자가 국적을 가지지 아니하거나 국적을 알 수 없는 경우에는 국적을 대신하는 연결점으로 상거소를 도입하고 있다.

여기서 말하는 “국적을 알 수 없는 경우”란 어느 나라의 국적을 가지고 있는지 국적의 유무 자체가 확실하지 않은 경우도 포함된다 고 할 것이다.

라. 불통일법국

불통일법국이란 동일한 주권 아래 복수의 법률계를 가진 나라를 말한다. 전형적으로는 각 주마다 다른 사법체계를 가진 미합중국의 경우가 대표적인 예이다. 이러한 국법이 준거법으로 지정된 경우에 그 국가의 여러 법역 중 어느 지역의 법을 준거법으로 적용해야 하는지가 국제사법상 문제가 된다.

우리 국제사법 제3조제3항은 “당사자가 지역에 따라 법을 달리하는 국가의 국적을 가지는 때에는 그 국가의 법 선택규정에 따라 지정되는 법에 의하고, 그러한 규정이 없는 때에는 당사자와 가장 밀접한 관련이 있는 지역의 법에 의한다.”고 규정하고 있다. 따라서 피상속인이 지역에 따라 법이 서로 다른 국가의 국적을 가진 경우에도 준거법 결정의 문제가 발생한다.

이에 대하여 구 섭외사법(제2조제3항)은 “그 자가 속하는 지방의 법에 의한다.”고 규정하여 그자가 속하는 지방의 법이 어떠한 법률을 의미하는가에 관하여 법문이 분명하지 않았기 때문에 그 해석을 놓고 학설의 대립이 있었다.

제1설은 직접지정설을 채용한 것이라는 견해로, 다시 이 견해는 그자가 속하는 지방의 법이란 본국에 있어서의 주소지의 법률이라는 견해와 본적지의 법률이라는 견해가 있다.

제2설은 이 문제는 본국의 보통법이나 준국제사법으로 하여금 결정하도록 하는 것이 합목적적이고 또한 당연하다는 견해로 간접지정설을 채용한 것이라는 견해로 통설이다.

개정된 국제사법은 통설인 간접지정설의 입장을 반영하여 우선 당해 국가의 법역간 충돌문제를 해결하는 법선택(준국제사법)에 따라 지정되는 법에 따르도록 규정하고 있다. 다만 당해 국가에 그러한 준국제사법이 없는 경우를 대비하여 그러한 규정이 없는 때에는

당사자와 가장 밀접한 관련이 있는 지역의 법에 의하도록 하였다(같은 법 제3조제3항).

제 3 절 | 각국의 상속준거법

외국인이 국내의 부동산을 취득하고 사망한 경우 그 상속인들이 상속을 함에 있어 어느 나라의 법을 상속의 준거법으로 해야 하는지가 문제가 된다. 여기에서는 세계 여러 나라 중에서 비교적 우리나라와 교류가 활발한 일본, 미국, 중국, 대만, 독일, 영국, 캐나다, 프랑스에 한정하여 상속의 준거법 및 상속을 증명하는 정보에 대해서 살펴보기로 한다.

1. 일 본

가. 준거법

일본국적의 피상속인이 한국 내에 부동산을 소유하고 있다가 사망한 경우 그 상속의 준거법은 사망 당시 피상속인의 본국법에 따르도록 하는 우리 국제사법 제49조제1항에 의해 피상속인의 본국법인 일본법을 따르게 될 것이다.

일본의 국제사법인 「법의 적용에 관한 통칙법」 제36조는 “상속은 피상속인의 본국법에 의한다.”고 규정하여 우리나라의 상속의 준거법 규정인 국제사법 제49조제1항과 같게 상속통일주의를 택하고 있다.

따라서 한국국적의 피상속인이 그 소유의 부동산을 일본에 남기

고 사망한 경우 법의 적용에 관한 통칙법 제36조에 의해 피상속인의 본국법인 한국법에 따르게 된다. 다만 재일동포인 대한민국 국민이 일본 민법이 정한 방식에 따라 공정증서에 의한 유언을 한 경우, 우리 국제사법 제50조제3항제3호에 따라 행위지법이 정한 방식에 따라서도 할 수 있으므로, 위 공정증서에 의해 한국 내에 소재하는 유언자의 부동산에 대하여 수증자 명의의 소유권이전등기를 신청할 수 있을 것이다(선례 5-332).

또한, 한국인인 갑의 사망 당시 상속인 중 일본에 거주하는 재외국민인 상속인 을이 있는 경우, 그가 일본 민법이 정하는 방식에 따라 상속포기를 하였다면 이를 유효한 것으로 보아야 할 것이다(선례 6-225).

위와 같이 상속의 준거법 결정은 일본의 국제사법에 따라 결정되지만, 상속인, 상속의 효력, 상속의 승인·포기 등에 대해서는 일본의 사법규정(민법 규정 등)에 의할 것이다.

나. 상속을 증명하는 정보

상속을 증명하는 정보로는 법정상속의 경우에는 호적등·초본을, 유산분할 등에 의한 경우에는 유산분할협의서, 상속 방기신술수리증명서(일종의 상속포기신고수리증명서) 및 특별수익증명서 등을 제출하여야 한다.

유언의 경우에는 피상속인이 유언으로 공동상속인 또는 그 일부의 상속분을 지정한 경우 등의 상속등기에는 호적(제적)등본 외에 유언서를 첨부해야 한다.

일본의 호적편제는 우리나라의 구 호적법과 같은 편제방법을 택하고 있다. 즉 이기기록이고, 인적기록이며, 가족단위기록이다. 또

한, 일본의 경우 호적의 편제원리는 일본국민기록원리, 신고주의, 이기등록원리, 인적편제카드방식, 가족카드방식 및 부부단위원리 등을 채택하고 있다.

일본의 호적편제는 가족카드 방식에 의한 물리적 연결기재와 편제변환에서의 색인적 연결기재 등으로 호적에 등재된 각자에 대해서 호적 기재만으로 그 직계, 방계 등 친족관계를 무한으로 또한 구체적으로 증명한다. 따라서 호적에 등재된 자가 사망한 경우 그 법정상속인 전원이 당해 호적에 의해서 쉽게 증명될 수 있다.

또한, 일본은 호적 및 제적에 대한 공개가 일반적으로 제한되지만, 상속관계를 증명할 필요가 있는 경우에 한하여 제3자라도 타인의 호적 및 제적등본의 교부청구가 인정된다고 한다.

2. 미 국

가. 준거법

미국국적의 피상속인이 한국 내에 부동산을 소유하다가 사망한 경우 그 상속의 준거법은 사망 당시 피상속인의 본국법에 따르도록 하는 우리 국제사법 제49조제1항에 의해 피상속인의 본국법인 미국 법을 따르게 될 것이다. 미국에 귀화한 한국인이 한국에 부동산을 남기고 사망한 경우에도 마찬가지이다.

그러나 국제사법 제9조(준거법 지정시의 반정)제1항에 의하면 외국법이 준거법으로 지정된 경우에 그 국가의 법에 의하여 대한민국의 법이 적용되어야 하는 때에는 대한민국의 법에 따라야 한다. 이때 미국의 국제사법이 부동산에 관한 상속에 대하여 소재지법 주의를 택하는지 여부가 문제 될 것이다.

이와 관련하여 미국의 국제사법에 상당하는 「Restatement of Conflict of Laws」 제249조에 의하면 토지의 상속에 대하여는 토지의 소재지국 법률에 따르도록 되어 있다. 따라서 한국 내에 부동산을 소유하는 미국국적자가 사망한 경우에 그 상속에 관하여는 한국의 법률이 적용된다. 미국의 국제사법에 상당하는 Restatement 란 미국은 각 주가 독립된 법역으로 법률의 내용도 복잡하므로 미국 법률협회가 현행 미국법률 중 유력하고 타당한 것을 간단한 조문의 형태로 체계적으로 재현한 것이다.

위에서 언급한 준거법은 사망 당시 피상속인의 국적을 가지고 있었던 나라의 법률이지만 미국이나 영국, 캐나다, 호주 등과 같이 지방에 따라 법률이 다른 나라의 국적을 가지는 경우에는 그 나라의 규칙에 따라 지정하는 법률이 준거법이며 규칙이 없는 때에는 그 당사자가 속하는 지방의 법률이 준거법이 된다.

영미법에서는 건물은 독립적인 부동산으로 취급하지 않고 토지의 경우는 토지만이 아니라 그 위에 있는 가택과 그 밖의 건조물도 포함되므로 부동산에 관한 상속에 관해서는 한국의 법률이 적용된다 할 것이다.

미국 시민권자인 유언자가 한국에 소재하는 자기 소유의 부동산에 대하여 유언을 하고자 할 경우에는 유언자의 본국법인 미국법이 정하고 있는 유언방식에 따라 할 수도 있고, 한국에서 한국법이 정하고 있는 유언방식에 따라 할 수도 있다(선례 5-333).

나. 상속을 증명하는 정보

상속을 증명하는 정보로는 법정상속의 경우에는 본국의 관공서 또는 재외공관의 증명이 있는 미국법에 의한 상속관계를 증명하는 서면

을 첨부한다. 만약 피상속인이 미국국적을 가지고 있는 외국국적 동포(원래 한국인)인 경우에는 제적등본도 필요하다.

공동상속인 사이에서 상속재산분할의 협의를 하였거나 상속인에 특별수익자가 있는 경우 등에 있어서는 위의 서면 외에 상속재산분할을 증명하는 서면, 상속분이 없는 것을 증명하는 서면 등을 첨부한다. 이들 서면에는 인감증명서 또는 본인의 서명날인임을 증명한다는 취지의 본국관공서나 미합중국 공증인의 증명에 의한 서면을 첨부한다. 이 경우에 서명자 본인이 당해 상속에 있어서 상속인 본인과 동일하다는 것이 공증된 선서서를 첨부할 필요는 없고, 미국 공증인의 자격을 증명하는 서면도 첨부할 필요 없다.

미국은 속지주의 국가로서 출생기록이 국민기록으로서 기능한다. 즉 미국인 개인별로 신분등록을 하며, 사건마다 각각의 신분등록을 하게 되어 있다. 따라서 미국의 신분기록부는 출생, 사망, 혼인으로 나뉘고 각각의 기록을 작성하여 보관한다. 즉 신분기록은 본인 한 사람만을 기록하고 가족관계는 기록하지 않기 때문에 그 결과 가족 전체는 한 번에 알 수가 없다. 이러한 사건별 편철등록시스템 때문에 중혼이나 근친혼의 발생을 방지할 수 없다고 한다. 이러한 문제 때문에 미국에서는 실질적인 개인식별제도로써 사회보장번호(Social security number)가 신원증명으로서 기능을 하고 있다.

또한, 개개인의 기록 간에 연결이 없으므로 개인신분사항도 한꺼번에 알 수도 없다. 따라서 누군가 사망하여 상속이 시작되어 그 자녀가 몇 명이고 그들 모두가 상속인이라는 것을 확인하려면 그 자녀 각각에 대한 출생증명서로서 그 하나하나를 확인해야 한다. 이 경우 대부분 잔존 배우자에게서 자녀의 출생연도를 확인하여 그 하나하나를 검색해야 한다.

이 같은 어려움 때문에 미국의 경우 상속에 있어서는 유언상속이 원칙이다. 즉 친족(가족)에 대한 기록이 없기 때문에 유언으로 구체적인 상속인을 정하는 것이다.

미국은 제3자가 마음대로 타인의 출생등록, 혼인등록, 사망증명을 흥미본위로 검색·열람하는 일은 허용되지 않으며, 정당한 이유가 없으면 이용할 수 없는 구조로 되어 있다.

3. 중 국

가. 준거법

우리나라에 부동산을 소유하고 있는 중국인(중화인민공화국인)이 사망한 경우에 당해 상속에 있어서의 준거법은 우리 국제사법 제49조에 의하여 피상속인의 본국법인 중화인민공화국의 법률이 된다. 이 경우에 중화인민공화국의 국제사법이 반정의 규정을 두고 있으면 한국의 법률이 적용되지만 그렇지 않으면 피상속인의 본국법에 의하게 된다.

여기서 본국의 상속 등에 관한 법률관계를 살펴보면 국제사법 문제를 처리하기 위한 중화인민공화국 민법통칙과 중국법을 적용하는 경우의 실질법인 중화인민공화국 계승법(상속법)을 들 수 있다.

중화인민공화국 민법통칙 제149조는 유산의 법정상속은 동산에 대하여는 피상속인의 사망 시의 주소지법을 적용하고 부동산에 대하여는 부동산의 소재지법을 각 적용한다고 규정하고 있다.

그리고 중화인민공화국 계승법 제36조는 중국공민이 중화인민공화국 경외에 있는 유산을 상속하거나 중화인민공화국 경내에 있는

외국인의 유산을 상속하는 경우에 있어 동산은 피상속인의 주소지의 법률을 적용하고 부동산은 부동산소재지의 법률을 적용한다고 규정하고 있다.

따라서 피상속인의 본국법인 중국법은 위와 같은 반정규정을 두고 있어 부동산의 소재지법인 한국법을 적용하게 된다.

나. 상속을 증명하는 정보

상속등기에 필요한 첨부정보로는 피상속인과 상속인을 증명하는 서면, 중화인민공화국 본국정부기관 또는 주한중국대사관이 발급한 국적·신분관계증명서 그 밖에 부동산소재지법인 한국 민법의 적용에 의한 각종의 서면으로 요약할 수 있다.

신청인이 그 본국법에 따라 사망자의 상속인이고 신청인 이외에 상속인이 존재하지 아니함을 증명하는 서면 또는 피상속인의 본국인 중화인민공화국의 본국정부기관이나 주한중국대사관 등이 증명 발급한 서면이 상속을 증명하는 정보가 된다.

예를 들어 “중화인민공화국의 법률에 의하여 아래의 사람이 사망한 자의 정당한 상속인으로서 유산을 승계하는 권한을 가진다.”라는 증명이 있으면 한국으로서는 이 증명내용에 따라 상속관계를 인정할 수 있으며 이 증명에 의하여 이 사람이 상속인이라는 것도 인정하게 된다.

중국 호적법은 호구등기조례이다. ‘조례’는 호구등기취지, 호구기록을 관리하는 행정기관, 호구부의 의의, 호구등기, 호구변동과 절차 등을 정한다.

중국의 신분등록제도 목적은 사회질서의 유지, 정부의 인구억제 정책, 인구이동의 제한 등으로 신분법상의 신분을 등록·공시하는

것은 중국 신분등록제도의 부차적인 목적에 불과하다. 따라서 중국에 있어서 호적제도는 정부가 사회를 제어하기 위한 기초로서 기능한다고 볼 수 있다.

그러나 호구등기부와 호구부에 등기한 사항은 인민의 신분을 증명하는 효력을 가지므로, 중국은 호구등기를 통하여 시민의 신분을 증명하고 시민의 법적 권익을 보호한다.

중국의 신분증명은 출생, 사망, 주소전출과 전입 4가지 사항이다. 또한, 중국의 신분등록제도는 우리나라나 일본과 같이 호적법과 주민등록제도로 이원화되어 있지는 않고, 호적제도와 주민등록제도의 목적을 하나의 제도로 시행하고 있다.

4. 대 만

가. 준거법

우리나라에 부동산을 가지고 있는 대만인(중화민국인)이 사망한 경우에 있어서의 상속의 준거법은 우리 국제사법 제49조제1항에 의하여 피상속인의 본국법인 대만(중화민국)의 법률이 된다.

그런데 우리나라는 대만과 그동안 국교를 맺어 왔으나 1992년 중국과 수교를 맺게 됨에 따라 국교를 단절하였다. 이 같은 경우에 있어서 그 구체적 준거법은 어떻게 되는가의 문제가 생긴다.

우리 국제사법 제3조제1항은 “당사자의 본국법에 의하여야 하는 경우에 당사자가 둘 이상의 국적을 가지는 때에는 그와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 그 본국법으로 정한다.”고 규정하고 있는 바, 이 규정을 유추적용하여 2개의 법질서 중 어떤 것이 그 사람이

속하는 국가의 법인가에 따라 본국법을 결정하고자 하는데, 이때는 불통일법국의 예에 의하여 처리하려는 전해가 유력하다고 한다.

따라서 대만인의 상속에 관한 준거법은 중화민국법에 반정의 규정이 없는 한 중화민국의 상속법이 준거법이 될 것이다.

나. 상속을 증명하는 정보

상속등기에 필요한 첨부정보로는 상속인을 증명하는 서면, 대만의 중화민국정부 발행의 신분관계증명서, 이 밖에 대만의 중화민국 상속법의 적용에 따른 각종의 상속을 증명하는 서면으로 요약할 수 있다.

대만 즉, 중화민국과의 국교는 이미 언급한 바와 같이 중국과의 수교로 국교가 단절되었고 이에 따라 주한중화민국대사관이 폐쇄되기에 이르렀다. 따라서 중화민국정부에서는 한국에 있어서 신분관계나 상속관계를 증명하는 기관이 없다.

그러나 중화민국정부가 발행한 호적(제적)등본을 주한타이베이 대표부가 증명하고 있는 경우에는 주한타이베이 대표부를 대만인의 한국에 있어서의 증명기관으로 평가해서 이것을 상속을 증명하는 서면으로 취급할 수는 있을 것이다.

대만 호적법에 따르면 호적편제방식은 적별(籍別)등기, 신분등기, 천도(遷都)등기 3종으로 구성되어 있으며, 이러한 등기는 우리나라의 가족관계등록제도, 주민등록제도 등에 해당하는 제도이다. 호적등기는 개인의 신분변동에 관한 사항 즉 출생, 혼인, 이혼, 사망 등을 등기한다. 대만의 경우 호적등본을 중국어, 영어로 발급받을 수 있다. 또한, 대만은 2000년에 호적사무 전산화를 완료하였고, 다만 제적부에 대해서는 전산화하지 않고 별도로 관리하고 있다고 한다.

5. 독 일

가. 준거법

독일인이 한국에 부동산을 남겨두고 사망한 경우의 준거법은 우리나라 국제사법 제49조제1항에 의하여 독일연방공화국의 본국법에 의한다. 따라서 독일의 상속에 관한 준거법인 독일 국제사법 제25조에 따르면 “사망에 의한 권리승계는 피상속인이 사망 당시 속하고 있었던 국가의 법에 따른다.”고 규정하여 우리나라 상속의 준거법과 같게 상속통일주의를 택하고 있다.

독일 민법 제1922조의 규정에 의하면 피상속인의 사망에 의하여 상속재산은 포괄적으로 상속인에게 귀속한다. 유언이 있는 경우에는 그 유언자의 의사인 유언내용이 우선한다.

또한, 독일 민법 제2174조는 유증에 의하여 수증자를 위한 유증 의무자로부터 유증목적물의 급부를 청구할 권리가 생긴다고 규정하여 유증은 채권적 효력밖에 없다고 한다.

따라서 독일의 경우에는 먼저 상속인에게 재산이 귀속되고 그 후에 상속인이 수증자에게 채무를 지는 형식으로 되어 있다. 등기는 한국의 경우처럼 피상속인의 명의로부터 직접 수증자 명의로 이전되는 것이 아니라 먼저 피상속인 명의로부터 상속인 명의로 이전하게 된다.

또한, 유언에 관하여 유언집행자의 권한 등이 문제가 되나 이것은 상속에 관련하는 것으로서 피상속인의 본국법인 독일법이 적용된다. 독일 법에서는 유언집행자는 원칙적으로 상속재산에 대해 상속인의 의견 등에 관여 없이 관리처분하는 권한을 가진다고 한다.

유언집행자는 상속재산을 처분하여 유산채무를 이행할 의무가 있으므로 상속재산을 매각할 권리가 있고 따라서 피상속인으로부터 상속인명의의 상속등기는 물론 상속인으로부터 제3자에 대한 매매 등기에 있어서도 등기신청권한이 유언집행자에게 있다고 한다.

나. 상속을 증명하는 정보

본국의 관공서 또는 재외공관의 증명에 의한 상속을 증명하는 서면의 제출이 필요하다. 이것은 법원에서 발행한 것이라도 좋고 주한 독일대사관에서 상속인을 누구와 누구라는 형태로 증명한 것이라도 상관이 없다.

유언집행자가 있는 경우에는 유언집행자라는 것을 증명하는 서면과 그 처분권한을 증명하는 서면이 필요하다. 유언서에서 유언집행자가 지정된 경우에는 그 서면만으로 족하며, 유언서는 법원의 확인이 있어야 한다.

독일에서 신분등록에 관한 법은 신분법이다. 이 법에 의하면, 독일 신분등록부는 출생, 혼인, 사망의 사건별 편제방식과 이를 보완하기 위한 난외부기방식, 가족단위편제방식을 채용하고 있다. 신분등록부에는 출생을 공증하기 위한 출생부, 혼인을 공증하기 위한 혼인부, 사망을 공증하기 위한 사망부, 친족관계를 분명히 하기 위한 가족부의 4종류가 있다.

따라서 어떤 사람이 사망하여 그 상속인의 범위가 문제 될 경우, 생존배우자, 혼인 중의 자 등은 사망자의 가족부에 등재되어 있는 이상 그의 존재는 명백하며 증명력을 가진다.

독일에서 신분등록증서의 교부 등에 대해서는 신중하게 취급되고 있다. 즉 신분등록부상의 본인, 배우자, 직계비속을 제외한 기타의

자는 스스로 법적 이해관계를 소명한 경우에 한하여 신분등록부상의 열람청구권과 신분증서의 교부청구권을 행사하도록 하고 있다.

6. 영 국

가. 준거법

영국인이 우리나라에 부동산을 소유하고 있다가 사망한 경우에 상속의 준거법은 우리나라 국제사법 제49조제1항에 의하여 피상속인인의 본국법이다. 그러나 영국법의 국제사법에 의하면 부동산에 관한 상속은 부동산의 소재지법에 따르게 되어 있어 우리나라 국제사법 제9조제1항에 의하여 한국의 법률이 적용된다.

나. 상속을 증명하는 정보

상속을 증명하는 서면은 본국의 관공서 및 재외공관의 증명에 의한다. 따라서 선서서와 진술서 등은 상속을 증명하는 서면이 될 수 없다.

영국 신분등록의 가장 큰 특징은 독일 및 프랑스와 같은 출생등록부, 결혼등록부, 사망등록부 상호 간의 색인기능이 없는 반면, 중앙등록제도가 존재하고 있어서 출생, 혼인, 사망 등 신분등록을 전국의 어느 등록지에서 등록하든지 간에 런던에 소재하고 있는 General Register Office에 집중되도록 하고 있다.

영국에서는 제3자가 타인의 신분관계를 조사하기 위한 시스템으로서 일반 공중에 공개되고 있는 색인을 위한 장소를 두고 있다. 그 장소에서 3개월마다 지방에서 송부되어 온 3가지 종류의 신분등록을 각각 출생·사망·혼인 사항별로 알파벳 순서로 그 사람의 이름

을 정리하여 이를 색인자료로 하고 있다. 이 색인자료 속에는 이름과 그 사항이 일어난 연월일과 일어난 장소, 예를 들어 출생은 언제, 어디에서 태어났다는 사실 및 출생자의 이름과 제 몇 권 몇 페이지에 그 기재가 있다는 등 등록부가 있는 장소가 기재되어 있다. 다만 이러한 사망, 출생, 혼인등록부 사이에 상호색인기능이 없다는 특징이 있다. 따라서 결혼상대방이 기혼자인지는 그 목적인물과 결혼사실에 대한 등록 사이에 연결되어있지 않기 때문에 알 수 없다.

General Register Office에서는 이러한 등록기록이 모두 마이크로필름으로 보관되어 있으며, 이를 이용하여 증명서나 등본을 작성한다.

영국의 중앙등록제도는 본국인이든 외국인이든 전부 하나의 신분등록시스템에 입력·관리된다. 이러한 등록부는 영구히 보존되므로 언제든지 확인 및 공증을 할 수 있다.

7. 캐나다

가. 준거법

캐나다 국적의 피상속인이 그 소유의 부동산을 한국에 남기고 사망한 경우에 있어서 상속에 관한 준거법은 우리 국제사법 제49조제1항에 의하여 피상속인의 본국법에 따르게 된다. 따라서 캐나다 법률에 의하게 되지만 캐나다는 국내에 복수의 다른 법역을 가지는 동일법이 정해져 있지 않은 나라이기 때문에 이 경우의 본국이란 무엇인가가 문제 될 것이다.

우리 국제사법 제3조(본국법)제3항은 “당사자가 지역에 따라 법을 달리하는 국가의 국적을 가지는 때에는 그 국가의 법 선택규정에

따라 지정되는 법에 의하고 그러한 규정이 없는 때에는 당사자와 가장 밀접한 관련이 있는 지역의 법에 의한다.”고 규정하고 있다.

캐나다에는 확실한 성문법으로서의 준국제사법은 없지만 영국연방에 속하여 있었기 때문에 Common Law가 계속 적용되었다는 역사적 사실로 Common Law의 원칙에 따라 그 사람의 거주지법이 가장 밀접한 관계가 있는 지역의 법률이 되고 당사자의 본국법이 된다고 한다.

예를 들어 캐나다 앨버타주의 법률에 따르면 부동산의 상속에 대해서는 그 부동산의 소재지법이 적용된다고 한다. 따라서 캐나다 국적의 피상속인이 앨버타주에 거주하고 있는 경우 상속의 준거법은 부동산의 소재지법인 우리나라의 법률이 된다.

나. 상속을 증명하는 정보

상속을 증명하는 서면으로는 본국의 관공서 및 재외공관의 증명에 의한 캐나다 상속관계를 증명하는 서면을 첨부한다.

8. 프랑스

가. 준거법

프랑스 국적의 피상속인이 한국에 부동산을 남겨두고 사망한 경우에 상속의 준거법은 우리나라 국제사법 제49조제1항에 의하여 피상속인의 본국법이 된다.

그러나 프랑스의 국제사법은 상속준거법의 결정에 관해서는 상속분할주의를 택하고 있다. 이에 따르면 부동산에 관한 상속문제는 반정 규정에 따라 부동산 소재지법을 따라야 하므로 부동산소재지

인 한국의 법률에 따라야 할 것이다.

나. 상속을 증명하는 정보

프랑스의 경우에는 상속의 준거법은 한국법률이므로 상속은 한국 민법에 의하여 결정되지만, 당해 신청인이 한국 민법이 규정하는 상속인이며 그 밖에 상속인이 되는 자가 없다는 것은 그와 같은 취지를 증명하는 본국정부기관 등의 증명서가 상속을 증명하는 서면이 될 것이다.

프랑스의 신분등록제도는 출생, 혼인, 사망이라는 세 가지 사항별로 되어 있으며 사건별 편제방식이다. 즉, 출생, 혼인, 사망이라는 세 가지 사항별 신분증서를 날짜순으로 신고인의 신고 등에 따라 신분등록 공무원이 작성한다. 또한, 프랑스에는 신분증서 외에 신분을 공증하는 것으로서 가족대장이 있다. 프랑스에서는 전통적으로 증명력이 인정되었던 것은 신분증서이고, 그 뒤 신분증서의 등본과 초본에도 원본과 같은 증명력을 인정하고 있다.

신분등록부의 출생·혼인증서는 그 공개를 엄격히 제한하여 타인에게서는 초본만을 발급하나, 사망증서는 그 제한이 없어 등본도 청구할 수 있다.

가족대장은 국가가 사람의 신분을 등기·공시하기 위한 것이 아니라 가족대장에 기록된 당사자가 그 신분을 공공기관에 증명하기 위한 것이다. 가족대장의 기록사항은 신분증서에 기록한 범위 내 사항이며, 신분증명서의 내용과 기능을 넘을 수 없다. 즉 신분증서가 공증하는 사항을 공증할 뿐이다.

이처럼 가족대장은 부부의 혼인증서초본, 자녀의 출생증서초본, 부부와 성년 전에 사망한 자녀의 사망증서초본과 같은 증명력을 가

지므로 행정사무를 처리하기 위해서 각각 그 신분등록지의 시·읍·면의 관청에서 증서발급을 하는 불편을 없앤 것이다. 가족대장은 공적서비스를 받을 때 그 신분증서를 갈음하여 제시할 수 있다.

제 4 절 | 외국인의 상속등기절차

1. 서 설

외국인이 피상속인이거나 상속인인 경우에도 그 상속등기신청은 한국인의 상속등기와 차이가 없다. 상속의 준거법에 관한 결정은 국제사법에 따르지만, 그 등기절차는 절차법의 문제이고 국제사법의 문제가 아니므로 우리나라의 부동산등기법이 적용될 것이다.

따라서 우리나라에 부동산을 소유하고 있다가 사망한 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 상속인이 누구인가 여부와 상속의 효력 등에 대해서는 원칙적으로 본국법에 의할 것이지만, 상속으로 인한 소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법에 따르게 된다.

외국인에 관한 상속등기의 절차도 법 제23조제3항의 신청인에 관한 규정, 규칙 제43조의 신청정보 및 제46조의 첨부정보에 관한 규정에 따라 등기신청을 하게 되므로, 이하에서는 일반절차와 다른 첨부정보에 대해서만 설명하기로 한다.

2. 첨부정보

가. 의 의

외국인에 관한 상속등기를 신청하는 경우에도 규칙 제46조에 따른 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다. 첨부정보 중에서는 상속을 증명하는 정보와 권리자의 등록번호 및 주소를 증명하는 정보가 가장 중요할 것이다.

등기신청서와 함께 외국관공서가 작성한 첨부정보가 제출된 경우에는 그 방식이나 취지 등에서 그 문서가 권한 있는 외국관공서가 직무상 작성한 것인가를 판단하여야 할 것이나, 그 판단이 어려울 경우에는 그 문서가 진정하게 성립되었음을 증명하는 다른 문서의 보완이 필요할 수 있다. 이러한 첨부정보가 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문을 첨부하여야 한다(규칙 제46조제8항).

나. 상속을 증명하는 정보

외국인의 상속등기는 당해 외국인의 본국법이 준거법이 되므로 당해 본국법에서 정하는 상속증명서에 의하여 상속인을 확정한다.

상속을 증명하는 정보는 그 상속인인 외국인의 국적에 따라 다르지만, 외국인의 본국법이 명백하고 또한 그 본국법이 정하는 상속증명서의 제출이 가능한 때에는 그 상속증명서를 상속을 증명하는 정보로 제공하면 된다. 그러나 외국인의 본국법이 명백하지 않거나 본국법이 정하는 상속증명서의 제출이 불가능할 때에는 본국관공서 또는 한국주재의 본국 재외공관 등의 증명서로서 이를 대신할 수 있다.

우리나라와 같은 가족관계제도를 가진 일본과 대만의 경우에는 이에 의하여 상속인의 범위를 정하는 것이 용이할 것이지만, 이러한 신분등록제도가 없거나 명백하지 않은 나라의 경우에는 그 제도에 의하여 상속인의 범위를 확정하는 것이 어려울 수 있다.

따라서 신분제도가 불명확한 경우에는 그 나라의 국민이 상속인으로서 상속등기신청을 할 경우에는 신청인이 상속인이라는 것 또는 신청인 이외의 상속인이 없다는 것을 당해 외국의 관공서가 증명한 서면을 상속을 증명하는 정보로 볼 수밖에 없다.

위에서 설명한 대로 일본이나 대만을 제외하고는 본국 정부기관이 발행한 상속증명서 등이 상속을 증명하는 서면으로 볼 수밖에 없을 것이다. 따라서 미국이나 영국처럼 당해국의 국제사법에서 부동산 소재지법인 한국의 법률을 적용하도록 한 경우, 즉 반정에 의하여 한국법에 준거하는 경우에도 당해 정부기관의 증명이 필요하게 된다.

다. 부동산등기용등록번호를 증명하는 정보

상속등기를 신청하는 경우에는 등기관리자의 성명(또는 명칭)과 함께 주민등록번호를 병기하여야 하고, 주민등록번호가 없는 경우에는 부동산등기용등록번호를 병기하여야 하므로(규칙 제43조제1항제2호), 그를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(규칙 제46조제1항제6호).

따라서 외국인이 등기명의인이 되기 위해서는 출입국관리사무소로부터 부동산등기용등록번호를 부여받아야 하고, 그를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다.

외국인의 등록번호는 체류지를 관할하는 출입국관리사무소장 또는 출입국관리사무소출장소장이 부여한다. 만일 국내에 체류지가 없는 경우에는 대법원 소재지 출입국관리소장 또는 출입국관리소출장소장이 이를 한다(법 제49조제1항제4호). 다만 국내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고번호(재외동포의 출입국

과 법적 지위에 관한 법률 제7조제1항)로 같음할 수 있다. 위와 같은 등록번호를 증명하는 정보는 외국인을 대위하여 등기신청을 하는 경우에도 마찬가지로 첨부정보로 제공하여야 한다(선례 5-116).

다만 공동상속인 중 국적을 상실한 사람이 있는 경우, 그 사람에 대해서도 부동산등기용등록번호를 증명하는 서면을 첨부정보로 제공하여야 하나, 그 상속인이 행방불명이 되어 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없는 경우에는 이를 소명하여 등록번호를 병기하지 아니하고 상속등기를 신청할 수 있다(선례 7-80).

라. 주소를 증명하는 정보

외국인이 상속등기를 함에 있어 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로 한국에 거주하는 경우에는 외국인등록사실증명서 또는 국내 거주사실증명서를, 그 밖에 외국인의 경우에는 그 본국 관공서의 주소증명서 또는 거주사실증명서(예를 들어, 일본, 독일, 프랑스, 대만 등의 경우)를 제공하여야 한다.

만약 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우(예를 들어, 미국, 영국 등의 경우)는 주소를 공증한 서면을 제공하여야 한다. 다만 이 경우에도 주소증명서에 대신할 수 있는 증명서(예컨대, 운전면허증 또는 신분증 등)를 본국 관공서에서 발급하는 경우, 관할 등기소의 등기관에게 그 증명서 및 원본과 같다는 취지를 기재한 사본을 제출하여 원본과 같음을 확인받은 때 또는 그 증명서의 사본에 원본과 같다는 취지를 기재하고 그에 대하여 본국 관공서의 증명이나 공증인의 공증 또는 외국주재 한국대사관이나 영사관의 확인을 받은 때에는 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 정보로 같음할 수 있다(예규 제1393호).

공동상속인 중 일부(갑)가 외국인(미국국적동포)인 경우에는 등기 신청서에 그 주소를 증명하는 서면으로 주소를 공증한 서면 등을 제공하여야 한다. 다만 갑이 위 주소를 공증한 서면 등의 제출에 협력하지 아니하는 경우에는 갑의 국외주소를 증명하는 그 밖의 다른 서면을 제출하여도 될 것이다(선례 7-171).

제11장 | 남북한 주민 간의 상속등기

제 1 절 | 총 설

남북한 간의 대립상태가 장기간 지속되는 상황에서도 남북 간의 교류증가와 탈북자의 국내입국 증가로 인하여 통일 이전에도 남북 이산가족의 가족관계 및 상속 등에 관련한 분쟁이 증가하고 있다. 최근 북한에 거주하는 북한 주민이 한국전쟁 때 월남한 아버지의 상속 재산을 반환해 달라며 상속회복청구 소송을 제기하고, 남한에서의 아버지의 중혼을 취소하라는 소송을 제기하는 등의 사례로 볼 때 남북 이산가족의 신분 및 재산에 관련된 분쟁의 소지가 커지고 있다.

이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 남북 주민 사이의 가족관계와 상속·유증 등에 관하여 분단의 특수성을 반영하여 민법 등에 대한 특례를 규정하고, 상속 등에 의하여 북한주민이 취득한 남한 내 재산의 관리에 관한 사항을 정하기 위해 「남북 주민 사이의 가족관계와 상속 등에 관한 특례법」(이하 이 장에서 “특례법”이라 한다)을 제정(법률 제11299호, 2012. 2. 10.)하였다.

여기에서는 특례법의 주요 내용 중 상속·유증 등과 관련되는 부분에 대해 개괄적으로 살펴보고, 남북 주민 사이의 상속 등의 등기 절차에 대해 설명하기로 한다.

제 2 절 | 특례법의 내용

1. 서 설

특례법은 남북한 주민 사이의 가족관계와 상속 등에 관한 법률관계와 향후 예상되는 법적 분쟁을 합리적으로 해결함을 목적으로 하고 있다. 이 법은 북한을 하나의 국가로 인정하지 않고 남북한의 관계가 국가 사이의 관계가 아닌 평화적 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계임을 반영할 수 있도록 법 적용 및 해석의 기본원칙을 정하고 있다(특례법 제2조).

남북한 주민 사이에 법적 분쟁이 발생할 경우 남한의 법원이 그 사건에 대해 관할을 가져야 하므로 특례법에서는 재판관할에 대해 특별 규정을 두고 있다. 즉 이 법이 적용되거나 그와 관련된 사건에서 법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 남한과 실질적 관련이 있는 경우에 재판관할을 가지되, 법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 재판관할의 유무를 판단하도록 하고 있다(특례법 제4조).

또한, 이 법이 적용되는 사건으로서 가사소송법 제2조에 따른 가정법원의 전속관할에 속하는 사건은 가정법원의 전속관할로 하고, 상속회복청구 사건은 가정법원 합의부의 전속관할로 하며, 북한주민의 재산관리인 선임·변경에 관한 사건은 북한주민의 재산소재지에 있는 가정법원의 전속관할로 한다(특례법 제5조).

2. 남북 주민 사이의 상속 등에 관한 특례

가. 상속재산반환의 청구

남북이산 후 이 법 공포일(2012. 2. 10.) 전에 실종선고(「부재선고에 관한 특별조치법」에 따른 부재선고를 포함한다)를 받은 북한주

민에 대하여 실종선고의 취소심판이 확정된 경우 실종선고의 취소 심판을 받은 사람은 실종선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자(그의 상속인을 포함한다)를 상대로 그 재산의 반환을 청구할 수 있다(특례법 제10조제1항). 이 규정은 실종선고(부재선고)를 받은 자가 현재 생존하여 있는 경우 그 생존자가 직접 재산의 반환청구를 하는 경우에 한정되고, 실종선고와 다른 때에 사망하였을 경우에는 상속재산반환이 아닌 상속인들 간의 상속회복청구 문제로 귀결될 것이다.

이러한 청구에 대해 반환청구의 상대방이 선의(善意)인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고, 악의(惡意)인 경우에는 그 받은 이익 중에서 이 법 공포일 당시에 현존하는 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다(특례법 제10조제2항).

다만 상속재산반환청구로 인한 제3자의 거래안전을 보호하기 위해 법 공포일까지 이루어진 제3자의 상속재산 취득행위는 선·악의를 불문하고 유효한 것으로 규정하고 있으며, 특례법 공포일부터 실종선고 취소심판의 확정 전까지는 선의로 행위를 한 제3자만 보호받을 수 있도록 규정을 두고 있다(특례법 제10조제3항).

남북이산 후 특례법 공포일 전에 실종선고(「부재선고에 관한 특별조치법」에 따른 부재선고를 포함한다) 외의 사유로 사망으로 처리된 북한주민이 생존하고 있는 경우에도 그 생존자는 사망처리를 직접 원인으로 하여 재산을 취득한 자(그의 상속인을 포함한다)를 상대로 그 재산의 반환을 청구할 수 있다. 이 경우에도 상속재산반환청구에 관한 특례를 적용한다(특례법 제10조제4항 및 제5항).

나. 상속회복의 청구

북한 주민이 남한 내의 부동산에 대해 상속인이 될 수 있는지가 문제가 되나, 판례는 “상속인이 이복에 있어 생사불명이라는 이유만으로 상속인에서 제외될 수는 없다.”고 판시하는 등 북한주민의 상속권도 남한주민과 동일하게 인정하고 있다(대법원 1982. 12. 28. 선고 81다451·453 판결). 북한도 대한민국 영토에 속하여 대한민국의 주권이 미치는 지역이고, 북한주민도 대한민국 국민이라는 점에서 북한주민의 상속권을 부정할 수는 없을 것이다.

이처럼 북한주민의 상속권을 인정한다면 북한주민의 상속회복청구권도 당연히 인정될 것이다. 따라서 남북이산으로 인하여 피상속인인 남한주민으로부터 상속을 받지 못한 북한주민(북한주민이었던 사람을 포함한다) 또는 그 법정대리인은 민법 제999조제1항에 따라 상속회복청구를 할 수 있다(특례법 제11조제1항 전문).

또한, 북한주민의 상속재산 관리의 어려움을 해결할 수 있도록 하기 위해 민법에 따른 상속회복청구의 소의 경우에도 북한주민에게 가액반환으로 청구할 수 있는 선택권을 주었으며(특례법 제11조제1항 후문), 피상속인을 부양하거나 피상속인의 재산증식에 기여한 남한주민에게 기여분을 인정하는 규정을 두고 있다(특례법 제11조제2항부터 제4항).

다. 상속의 단순승인 간주에 대한 특례

민법은 상속의 승인, 포기의 기간과 관련하여 “상속인은 상속개시 있음을 안 날로부터 3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다.”고 규정하고 있다(민법 제1019조제1항). 그러나 북한주민은 피상속인의 사망으로 상속이 개시된 사실을 알 수 없기 때문에

상속개시가 있음을 안 날로부터 3월내에 상속의 승인, 포기를 할 수 없을 것이다.

따라서 특례법은 상속개시 당시 북한주민(북한주민이었던 사람을 포함한다)인 상속인이 분단으로 인하여 민법 제1019조제1항의 기간 내에 한정승인 또는 포기를 하지 못한 경우 민법 제1026조제2호에 의해 단순승인으로 간주되어 채무초과인 남한의 피상속인의 채무까지 상속되는 문제가 있으므로, 북한주민을 보호하기 위하여 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 책임이 있는 것으로 규정하고 있다(특례법 제12조).

3. 북한주민의 상속·유증재산 등의 관리

가. 재산관리인의 선임

북한주민이 남한 내 부동산에 대해 상속 등에 의해 권리를 취득하는 경우에도 현실적으로 그러한 취득 및 처분행위에 어려움이 있으므로, 북한주민이 그 재산을 실질적으로 관리할 수 있을 때까지는 그 재산을 대신 관리해 줄 재산관리인이 필요할 것이다.

특례법은 이러한 측면에서 북한주민의 법정대리인으로서 재산관리인제도를 규정하고 있다. 즉 북한주민이 남한 내에 상속·유증재산 등을 취득한 경우에는 재산관리인을 선임하여야 하고, 그 재산관리인이 북한주민의 남한 내 관리·처분 등을 하여야 하며, 재산관리인에게 신고 등 일정의무를 부과하고 있다(특례법 제13조부터 제18조).

북한주민이 재산관리인을 통하지 아니하고 상속 등에 관하여 한 법률행위를 직접 한 경우는 이를 무효로 한다. 다만 북한주민이 직

접 사용·관리하도록 허가받은 재산은 재산관리인을 통하지 않고 사용·관리할 수 있으므로 특례법 제19조에 따라 법무부장관의 허가를 받은 경우에는 그 법률행위가 유효하다고 할 것이다(특례법 제15조).

재산관리인이 민법 제118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 하려는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 사전에 법무부장관의 허가를 받아야 하고, 허가를 받지 아니한 처분이나 계약은 무효로 한다(특례법 제18조).

또한, 특례법 부칙 제3조는 이 법 시행 전에 상속·유증 등을 원인으로 취득한 재산에 관하여도 재산관리인 선임, 직접 사용·관리 제한 등 이 법의 관련 규정을 적용할 필요가 있으므로 이에 대하여 명시적으로 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 이 법 시행 전에 북한주민이 남한 내 재산을 취득한 경우에는 이 법 시행일로부터 1개월 이내에 재산관리인 선임을 청구하여야 할 것이다.

나. 북한주민의 직접 사용·관리

북한주민은 원칙적으로 남한 내 재산을 취득하더라도 재산관리인을 선임하여 그 재산을 관리하여야 하나, 예외적으로 인도주의 차원에서 생계유지나 질병치료 등의 사유로 법무부장관의 허가를 받은 경우에는 북한주민이 직접 사용·관리할 수 있도록 하고 있다(특례법 제19조).

다. 상속재산 등을 취득한 북한주민의 등록대장

북한주민이 남한 내 재산을 상속 등을 받는 경우 이를 체계적으로 관리하기 위해서는 그 북한주민에 관한 인적사항 및 상속 등의 취득

에 관한 사항을 등록할 필요가 있다. 특례법 제21조는 이러한 필요에 따라 작성하는 북한주민의 등록대장에 관하여 규정하고 있다.

북한주민의 등록대장은 법무부장관이 북한주민 개인별로 구분하여 등록·관리하여야 하고, 등록대장에 등록된 북한주민에 대하여는 개인별로 고유한 등록번호를 부여하여야 한다. 북한주민이 남한 내 부동산을 등기하는 경우에는 북한주민등록번호는 부동산등기법 제49조에 따라 부여된 부동산등기용등록번호로 본다(특례법 제21조).

제 3 절 | 남북 주민 사이의 상속·유증 등의 등기

1. 서 설

북한주민이 특례법에 의해 남한 내 재산을 상속·유증 등을 통해 취득하는 때에 그 재산이 부동산인 경우에는 부동산등기를 하여야 할 것이다. 북한주민이 부동산등기를 하는 경우에도 등기절차는 일반적인 절차와 같으나, 특례법이 남북 주민 사이의 특정한 원인에 의한 권리취득만을 규정하고 있기 때문에 그 적용범위에 대해서 살펴볼 필요가 있다.

또한, 특례법을 원인으로 하는 등기를 신청하는 때에는 신청정보 및 첨부정보에 대해서는 특례법 및 등기에규에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 일반적인 절차와 같다.

이하에서는 특례법 시행에 따른 남북 주민 사이의 부동산등기의 적용범위와 특수한 신청정보 및 첨부정보에 관해서 “남북 주민 사이

의 가족관계와 상속 등에 관한 특례법 시행에 따른 업무처리지침”(예규 제1457호)을 중심으로 설명하기로 한다.

2. 적용범위

특례법은 남한주민과 북한주민 사이의 상속·유증 등에 관한 관계를 규율하기 때문에 현재 남한과 북한주민은 당연히 적용됨은 물론 최근 탈북자 증가에 따라 기존에 북한주민이었던 사람도 포함한다.

특례법은 남북 주민 사이에 상속, 유증 및 특례법 제10조를 원인으로 하는 경우에만 적용된다고 할 것이다. 따라서 특례법에 정한 이외의 사유를 원인으로 하는 경우에는 특례법이 적용되지 않는다. 예를 들어 매매 또는 증여를 원인으로 하여 북한주민이 남한 내 부동산을 취득하는 경우에는 등록번호 및 주소를 증명하는 서면으로 법무부장관이 발급한 확인서를 첨부하여 등기신청을 할 수는 없을 것이다.

3. 신청인

북한주민이 특례법에 따라 남한 내 부동산에 관한 권리를 취득하여 그 취득에 관한 등기를 하는 경우에 등기의무자는 남한 내 재산을 소유하고 있는 피상속인 또는 유언자 등이고, 등기권리자는 상속·유증 등으로 남한 내 부동산에 관한 권리를 취득한 북한주민이다.

다만 특례법에 따라 북한주민이 남한 내 부동산에 관한 권리를 취

득하는 경우에는 원칙적으로 재산관리인의 선임을 청구하여 그 재산관리인을 통하여 상속·유증 등에 관한 법률행위를 하여야 한다. 따라서 특례법에 따른 북한주민의 상속·유증 등에 관한 등기는 법원이 선임한 재산관리인이 북한주민을 대리하여 신청하여야 한다(예규 제1457호 제3조).

4. 신청정보

일반적으로 등기를 신청하는 경우에는 규칙 제43조에 규정된 사항으로 부동산표시에 관한 사항, 신청인의 성명 또는 명칭과 주소 및 주민등록번호, 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 성명과 주소, 등기원인과 그 연월일, 등기의 목적, 등기필정보, 등기소의 표시, 등기신청연월일 등을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다.

다만 특례법에 따른 등기신청에 있어 등기권리자인 북한주민의 표시는 법무부장관이 발급한 북한주민등록번호 및 주소확인서에 기재된 사항을 규칙 제43조제1항제2호의 신청정보로 제공하여야 할 것이다(예규 제1457호 제4조).

또한, 재산관리인이 북한주민을 대리하여 신청하여야 하므로 신청인을 “등기권리자 ○○○, 재산관리인 ○○○”로 표시하고 재산관리인의 주소를 기재하여야 한다.

5. 첨부정보

특례법에 따라 북한주민이 남한 내 부동산에 관한 등기를 신청하는

경우에도 일반적인 첨부정보는 같다. 다만 앞에서 설명한 바와 같이 특례법에 따른 등기는 북한주민의 표시 및 재산관리인 선임 등과 같이 특례법에서 정한 특수한 첨부정보가 요구되므로 이하에서는 이러한 첨부정보에 대해서만 설명하기로 한다.

가. 북한주민의 재산관리인임을 증명하는 정보

특례법에 따라 상속·유증 등에 재산을 취득하는 경우에는 재산관리인을 선임하도록 강제하고 있기 때문에 이를 원인으로 하는 등기를 신청할 때에는 북한주민의 재산관리인임을 증명하는 정보를 첨부하여야 한다(예규 제1457호 제5조제1항). 이때 재산관리인임을 증명하는 정보는 법원의 재산관리인 선임결정문이 될 것이다.

북한주민의 재산관리인으로 법무부장관에게 선임신고서를 제출한 선임신고서나 신고와 관련한 그 밖의 양식은 재산관리인을 선임하는 정보가 될 수 없다.

나. 북한주민의 등록번호 및 주소 확인서

북한주민이 남한 내 재산을 취득하는 경우 이를 관리하거나 등기를 하기 위해서는 북한주민의 인적사항에 대한 정보가 필요할 것이다. 특례법은 이러한 필요에 따라 북한주민의 등록대장에 관하여 규정하고 있다.

따라서 북한주민의 남한 내 부동산에 대하여 등기를 신청하는 경우에는 북한주민의 등록번호 및 주소를 증명하는 정보로 법무부장관이 발행한 북한주민등록번호 및 주소 확인서를 첨부정보로 등기소에 제공하여야 한다(특례법시행령 제14조, 동시행규칙 제10조, 예규 제1457호 제5조제1항).

특별법 시행 이전의 등기실무는 만약 6.25사변 당시 월남한 유언자가 우리나라 호적에 등재되어 있지 아니한 북한에 두고 온 처와 5인의 자녀에게 전 재산을 유증한 경우에는 신청인인 수증자들의 주소 등을 소명할 수 없으므로 유증으로 인한 소유권이전등기는 신청할 수 없다는 입장이나(선례 5-323), 특별법 시행 이후부터는 위와 같은 등기신청도 가능하다고 할 것이다.

다. 북한주민의 재산처분 등 허가서

재산관리인이 민법 제118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 하려는 때에는 사전에 법무부장관의 허가를 받아야 하므로(특별법 제18조), 이러한 처분행위를 원인으로 하는 등기를 신청하는 경우에는 법무부장관이 발급한 북한주민 재산처분 등 허가서를 첨부정보로 제공하여야 한다.

재산관리인이 특별법 제18조제1항에 따라 법무부장관의 허가를 받고도 처분 등을 할 수 있는 허가기간 내에 허가받은 행위를 하지 않은 경우에는 그 효력이 상실되므로(특별법시행령 제5조제3항), 위 허가기간이 도과한 경우에는 허가서를 제공하지 않은 것으로 본다(예규 제1457호 제5조제2항).

라. 재산관리인의 인감증명

특별법에 따른 등기를 신청하는 경우에는 재산관리인이 북한주민을 대리하여 신청하기 때문에 그 등기신청이 규칙 제60조에 따라 인감증명의 제출이 필요한 경우에는 재산관리인의 인감증명을 제공하여야 할 것이다(예규 제1457호 제5조제3항).

6. 등기관 의 심사

특례법의 제정 취지에 대해서는 앞에서 설명한 바와 같다. 이 법에 따른 등기신청이 있는 경우 등기관은 특례법 등에서 정하고 있는 첨부정보에 유의해서 사건을 처리하여야 할 것이다.

특히 재산관리인이 민법 제118조를 초과하는 처분행위를 원인으로 하는 등기신청을 하는 경우 등기기록상 등기명의인이 북한주민이라는 사실에 주의하여 북한주민 재산처분 등 허가서의 첨부 여부를 중점적으로 심사하여야 한다.

제12장 | 상속등기의 관련 문제

제 1 절 | 총 설

상속은 피상속인의 사망과 동시에 상속인이 피상속인의 재산을 포괄적으로 승계한다. 상속재산이 부동산인 경우에는 민법 제187조의 규정에 따라 등기 없이 그 부동산에 대한 소유권을 취득하지만, 상속등기를 마치지 아니하면 상속인은 이를 처분할 수 없다.

일반적으로 부동산등기는 등기권리자와 등기의무자 또는 그 대리인이 신청하여야 하지만 상속을 원인으로 하는 등기신청은 상속인이 단독으로 신청할 수 있다. 상속은 피상속인의 사망으로 개시되고 현실적으로 등기를 신청하는 경우 그 시점에 등기의무자인 피상속인이 현존하지 않으므로 성질상 공동신청이 불가능하고, 또한 피상속인의 사망사실은 증명하는 첨부정보에 의해 명백히 나타나기 때문이다.

이와 관련하여 하나의 부동산에 여러 차례 상속이 발생한 경우 상속등기의 중간생략등기가 인정되는지 여부, 법인 아닌 사단이나 재단의 대표자나 관리자가 사망한 경우 상속등기를 해야 하는지 여부, 등기원인이 이미 존재하고 있으나 등기신청을 하지 않고 있는 동안에 등기의무자나 등기권리자에 대하여 상속이 개시된 경우에 상속등기를 해야 하는지 여부 및 판결에 의한 등기신청 시 그 일방에 지위의 승계가 있는 경우 승계집행문을 부여받아 등기를 신청하여야 하는지 등이 문제 된다.

이 중에서 상속인에 의한 등기신청은 이미 앞에서 설명하였으므

로 이를 제외하고 나머지 문제를 살펴보기로 한다.

제 2 절 | 상속등기의 중간생략등기 가부

1. 의 의

중간생략등기란 부동산물권이 최초의 양도인으로부터 중간취득자에게 다시 중간취득자로부터 최후의 양수인에게 전전 이전되어야 할 경우에, 중간취득자 명의의 등기를 생략한 채 최초의 양도인으로부터 최후의 양수인에게 직접 행해진 등기를 말한다.

중간생략등기는 물권변동의 과정이 제대로 공시되지 못한다는 문제점이 있으며, 취득세 등 각종의 세금을 면탈할 수 있을 뿐만 아니라 부동산투기의 수단으로 악용되기도 한다.

중간생략등기의 유효성에 대하여, 학설과 판례는 중간취득자 명의의 등기가 생략되었더라도 최종취득자 명의의 등기가 현재의 권리상태를 공시하고 있기 때문에, 원칙적으로 중간취득자의 동의 또는 3자의 합의가 있는 상태에서 경료된 중간생략등기의 유효성을 인정하고 있다(대법원 1997. 5. 16. 선고 97가485 판결).

따라서 “최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 중간생략등기를 청구하기 위해서는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지만, 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 중간생략등기가 이루어진 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로 중간생략등기가 무효라고 할 수는 없다.”고 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2003다40651 판결).

상속등기의 경우 갑이 사망하여 그 부동산을 을이 상속하고, 다시 을이 사망하여 병이 상속한 경우처럼 부동산에 관한 상속이 수차례 개시된 경우, 부동산권리변동의 과정과 태양을 공시하기 위하여 상속이 개시된 때마다 차례로 각각 상속등기를 하여야 한다. 이때 수차례 상속이 개시되었는데도 각각 상속등기를 하지 않은 경우, 중간상속인 명의로의 상속등기를 생략할 수 있을지가 문제 된다.

2. 상속등기의 중간생략등기가 인정되는지 여부

상속등기에 있어 중간생략등기가 인정되는지 여부에 대해서는 부정적인 견해가 있을 수 있다. 즉 상속이 권리변동의 원인이므로 상속등기는 권리의 변동과정을 증명하는 것이지만 그 중간을 생략한다는 것 자체가 기본원칙에서 벗어나는 것이고, 또한 보통의 부동산 거래에서도 예외적으로 중간생략등기가 인정된다는 이유로 상속등기에는 중간생략등기가 인정될 수 없다는 견해다. 이 견해에 의하면 앞의 사례에서 을과 병은 각각 단독으로 상속등기를 신청하여야 할 것이다.

긍정적인 견해로는 주로 등기실무의 입장으로, 상속등기신청에 중간상속인의 사망과 같이 등기원인이 2개 이상 있을 때에는 먼저 개시된 상속으로 인한 등기원인과 그 연월일을 기재하고, 신청인 표시란에 “공동상속인 중 ○○○는 ○년 ○월 ○일 사망하였으므로 상속”으로 그 취지를 기재하면 가능하다는 견해이다. 즉 중간상속인 명의로의 상속등기를 생략하여도 등기원인에 중간상속의 상속인과 상속 연월일을 기재하는 것에 의하여 권리변동의 과정과 태양을 공시하는 것이 가능하다는 점, 또한 그것에 의하여 중간상속인의 이익

을 해할 염려가 없다는 점, 중간상속인 명의의 상속등기가 생략되더라도 최종상속인 명의의 등기는 현재의 권리상태를公示하기 때문에 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 없으며 거래안전을 고려할 때 상속등기의 중간생략등기를 인정할 수 있다고 한다. 이러한 입장의 등기기록례는 앞의 상속으로 인한 소유권이전등기 편에서 설명한 바 있다.

따라서 상속이 개시된 이후 그 상속등기를 하기 전에 공동상속인 중 1인이 사망하여 또 다시 상속이 개시된 경우, 예를 들어 갑이 사망하고 을과 병이 공동상속한 후에 상속등기를 하지 않은 채 을이 사망하여 그의 직계비속 정이 상속한 경우처럼 병과 정의 지분취득의 등기원인이 각각 다른 경우에도 순차로 상속등기를 할 것이 요구되지 아니하고 최후의 상속인 앞으로 직접 상속등기를 신청할 수 있다고 할 것이다. 이 경우에는 상속개시일자를 순차로 모두 기재하여 1건으로 상속등기를 신청할 수 있으므로, 중간상속인 명의로의 상속등기가 생략된 경우와 동일하다고 할 수 있다.

제 3 절 | 상속과 소유권이전등기의무

1. 법인 아닌 사단·재단의 대표자 또는 관리자가 사망한 경우

법인 아닌 사단·재단의 전대표자 명의로 소유권등기가 된 부동산에 대하여 법인 아닌 사단이 제3자에게 그 소유권을 양도한 경우, 법인 아닌 사단의 새로운 대표자 명의로 소유권이전등기를 한 후에 제3자에게 소유권이전등기를 하여야 할 것인지가 문제될 수 있다.

가. 일본의 경우

일본은 우리나라와 달리 법인 아닌 사단의 등기능력을 규정하고 있지 않기 때문에 일본의 등기실무는 법인 아닌 사단 명의로의 등기에 대하여 소극적인 입장을 취하고 있다. 즉 법인 아닌 사단의 재산은 그 구성원 전원의 총유로 귀속하고 사단 자체는 사법상 권리주체로 되는 것이 아니기 때문에, 법인 아닌 사단의 재산으로 되어 있는 부동산은 대표자 명의로 등기를 하는 것으로 위임이 있었다고 할 수 있으며, 신탁적으로 대표자 개인에게 귀속하는 것으로서 대표자 명의로 등기가 된다고 한다. 따라서 법인 아닌 사단의 대표자가 사임 또는 사망으로 인해 위임이 종료된 경우에는 법인 아닌 사단의 새로운 대표자에게 등기명의를 이전해야 한다고 한다.

나. 우리나라의 경우

일본과는 달리 우리나라는 법인 아닌 사단 등에 대해서 등기능력을 인정하고 있다. 즉 부동산등기법 제26조제1항에서 “종중(宗中), 문중(門中), 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단(社團)이나 재단(財團)에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.”고 하여 등기능력을 인정하고 있고, 제2항에서는 “제1항의 등기는 그 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.”고 하여 대표자나 관리인이 등기신청인임을 규정하고 있다. 다만 법인의 경우에는 대표기관의 표시가 등기사항이지만, 법인 아닌 사단이나 재단의 경우에는 법인 등기사항증명서와 같은 공시제도가 없기 때문에 그 대표자나 관리인을 분명히 공시할 필요가 있으므로, 그 대표자나 관리인의 성명, 주소 및 주민등록번호를 등기사항으로 하고 있다(법 제48조제3항).

따라서 법인 아닌 사단 등의 전대표자 명의로 소유권등기가 된 부동산에 대하여 법인 아닌 사단 등이 제3자에게 소유권을 양도한 경우에는 새로운 대표자 명의로 등기명의인표시변경등기를 한 후 제3자 명의로 소유권이전등기를 하여야 할 것이다.

2. 수탁자가 사망한 경우

신탁법상 신탁이란 신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)와 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 제1조제2항). 신탁법상 신탁은 신탁재산이 대내적으로는 물론 대외적으로도 수탁자에게 이전되고, 다만 수탁자는 신탁등기가 됨으로써 신탁목적을 위하여 그 신탁재산을 관리하고 처분하여야 하는 구속을 받을 뿐이다.

신탁재산의 소유권은 수탁자에게 대·내외적으로 이전되므로 유일한 수탁자가 사망한 경우, 신탁사무는 종료하게 되고 신탁재산의 상속인에게 소유권이 이전되는지 또는 새로운 수탁자와 상속인이 공동으로 이전등기를 신청해야 하는지가 문제 된다.

신탁법 제23조는 “신탁재산은 수탁자의 상속재산에 속하지 아니하며, 수탁자의 이혼에 따른 재산분할의 대상이 되지 아니한다.”고 규정하고 있다. 또한, 같은 법 제11조는 “수탁자가 사망한 경우에는 그 임무는 종료되고, 수탁자의 상속인은 신수탁자가 신탁사무를 처리할 수 있게 될 때까지 신탁재산을 보관하고 신탁사무인에게 필요한 행위를 하여야 한다.”고 하고 있다.

이러한 신탁법 규정에 따르면 수탁자의 사망으로 임무가 종료되더라도 수탁자의 상속인은 수탁자 지위를 승계하지 않으므로 신탁 재산에 대해 그 보관과 신탁사무인계에 필요한 행위를 함에 그치고, 신탁재산에 대한 적극적 운영의무는 없다고 할 것이다.

수탁자의 사망으로 인한 임무종료에 따른 등기신청에 관해 법 제 83조는 새로 선임된 수탁자가 단독으로 이전등기를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 즉 신탁재산은 상속재산으로부터 독립적으로 존재하고, 공동신청에 의하지 않더라도 등기의 진정이 확보될 수 있기 때문에 새로운 수탁자가 단독으로 이전등기를 신청할 수 있도록 한 것이다.

3. 판결에 의한 등기와 승계집행문

가. 의 의

부동산등기는 등기관리자와 등기의무자의 공동신청에 의하여야 하는데(법 제23조제1항), 등기의무자가 등기신청에 협력하지 않은 경우에 등기관리자가 등기에 협력하여 줄 것을 청구할 수 있는 실체 법상의 등기청구권이 인정된다.

이러한 등기청구권을 근거로 하여 등기관리자가 등기의무자를 상대로 한 소송에서 일정한 내용의 등기절차를 이행할 것을 명하는 판결이 확정되면 그것으로써 등기의무자가 등기신청을 한 것으로 간주되므로(민사집행법 제263조), 승소한 등기관리자는 그 확정판결에 기하여 단독으로 등기신청을 할 수 있다.

확정판결의 효력은 당사자, 변론종결 후의 승계인(변론종결 없이 한 판결의 경우에는 판결선고 후의 승계인) 또는 그를 위하여 청구

의 목적물을 소지한 사람에 대하여 미치므로(민사소송법 제218조제1항), 판결의 확정 기타 집행권원의 성립 후에 당사자의 승계가 있는 경우 승계인을 위하여 또는 승계인에 대하여 집행하기 위해서는 승계집행문을 부여받아야 한다(민사집행법 제31조).

여기에서 의사진술을 명하는 소송에서 변론을 종결한 뒤에 등기관리자나 등기의무자의 지위에 승계가 있는 경우에 어느 경우에 승계집행문을 부여받아야 등기신청을 할 수 있는지가 문제 된다.

나. 등기의무자의 지위에 승계가 발생한 경우

(1) 변론종결 전에 상속이 개시된 경우

변론종결 전에 승계가 된 경우에는 소송승계가 되어 원래의 당사자와 승계인 간에 재판이 이루어진다. 상속의 경우 판결 전에 승계사실과 승계인이 판명되었다면 따로 소송수계절차를 밟을 필요 없이 판결에 승계인(망 갑의 상속인 을)을 당사자로 표시하여야 하며 이 경우에는 승계집행문 부여가 문제가 되지 않는다.

이와 달리 당사자의 사망에 의한 소송절차의 중단을 간과하고 선고된 판결의 효력 및 그 판결에 기하여 승계집행문을 부여받을 수 있는지가 문제가 된다.

판례는 “소송계속 중 어느 일방 당사자의 사망에 의한 소송절차 중단을 간과하고 변론이 종결되어 판결이 선고된 경우에는 그 판결은 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되는 절차상 위법은 있지만, 그 판결이 당연무효라 할 수는 없고, 다만 그 판결은 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 보아 대리권흠결을 이유로 상소 또는 재심에 의하여 그 취소를 구할 수 있을 뿐이므로, 이와 같이 사망한 자가 당사자로 표시

된 판결에 기하여 사망자의 승계인을 위한 또는 사망자의 승계인에 대한 강제집행을 실시하기 위해서는 민사집행법 제31조를 준용하여 승계집행문을 부여함이 상당하다.”고 한다(대법원 1998. 5. 30. 자 98그7 결정, 대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다34038 판결). 따라서 변론종결 전에 피고 을이 사망한 경우, 원고 갑은 사망한 피고의 상속인에 대한 승계집행문을 부여받아 판결에 의한 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

(2) 변론종결 후에 상속이 개시된 경우

변론종결 후 피상속인이 사망한 경우, 예를 들어 을소유 부동산을 갑이 매수한 후 갑이 을을 피고로 하여 소유권이전청구의 재판 중 변론종결 후 등기의무자인 피고 을이 사망한 경우 승계집행의 문제가 발생하는지가 문제이다.

이에 대해서는 갑은 민사집행법 제31조에 의하여 을의 상속인에 대하여 가족관계등록부 등을 첨부하여 승계집행문부여신청을 하여 승소판결에 기한 등기를 신청할 수 있다는 견해가 있으나, 등기실무는 을의 상속인은 변론종결 후의 승계인이 아니므로 승계집행은 문제가 되지 않고, 갑은 법 제27조라는 특례규정에 의하여 판결에 의한 등기를 할 수 있다는 입장이다. 또한, 을로부터 그 상속인 명의로 등기가 이루어진 경우에도 그 등기를 그대로 둔 채 자기 앞으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

다. 등기권리자의 지위에 승계가 발생한 경우

등기권리자의 지위에 승계가 발생한 경우, 예를 들어 을소유 부동산에 대하여 갑이 매매를 원인으로 한 소유권이전등기소송을 제기

하고 그 변론종결 후에 매수인 갑이 사망한 경우, 민사집행법 제31조에 의하여 갑의 상속인이 가족관계등록부 등을 첨부하여 승계집행문부여신청을 하여 승소판결에 기한 등기를 신청할 수 있는지가 문제 된다.

이에 대해서는 등기실무에서 법 제27조의 포괄승계인에 의한 등기신청의 법리를 적용하여 등기관리자의 지위를 승계한 상속인이 상속을 증명하는 정보를 제공하여 등기신청을 할 수 있기 때문에, 원고의 지위를 승계한 상속인이 이와 별도로 승계집행문부여신청을 할 필요는 없는 것으로 하고 있다. 등기선례는 원고가 판결확정 후 사망한 경우이든(선례 7-107), 변론종결 후 사망한 경우이든(선례 4-257) 같은 것으로 본다.

색 인

ㄱ	
가족인 모의 상속인	30
가족인 처의 상속인	30
각국의 상속준거법	300
강제보존주의	2
강제분할주의	2
강제상속	4
검인	235
검인절차	239
경정등기절차	183
계모자	36
고려기간	138
고려기간에 대한 특칙	139
고려기간의 기산점	138
고려기간의 연장	139
공동상속	4, 86
공동상속인	86
공동상속인이 행방불명된 경우	180
공동상속주의	2
공동유언집행자	273
공정증서에 의한 유언	236
구관습법	13
구관습법상 상속분	32
구관습법상 재산상속의 특색	17
구관습법상 호주상속의 순위	15
구관습법상의 재산상속	16
구관습법상의 호주상속	14
구수증서에 의한 유언	241
국적	297

균분상속	5
금양임야	84
기여분의 결정	103
기여분제도	9
기여상속인의 상속분	101

ㄴ	
남북 주민 사이의 상속 등에 관한 특례	321
남북 주민 사이의 상속·유증 등의 등기	326
녹음에 의한 유언	235

ㄷ	
단독상속	4
단독상속주의	2
단순승인	144
단순승인의 효과	147
대리유언	228
대만	307
대습상속	64
대습상속의 성질	65
대습상속의 요건	66
대습상속의 효과	69
독일	309
동성이복	60
동시사망의 추정	48
등기권리자의 지위에 승계가	

발생한 경우	340
증기의무자의 지위에 승계가	
발생한 경우	339

□

묘토	84
무국적	297
무후가	27
미국	302

ㅅ

반정	296
방계혈족의 범위	36
배우자	61
배우자 상속권의 변화	37
배우자의 대습상속	63
배우자의 상속지분	63
법정단순승인	144
법정상속	4
법정상속분	93
부담부 유증	262
부담부 유증의 취소	264
부담부 유증의 효력	263
부담의 내용	262
부재자재산관리인	120
북한주민의 등록대장	325
북한주민의 등록번호 및	
주소 확인서	329
북한주민의 재산관리인임을	

증명하는 정보	329
북한주민의 재산처분 등 허가서	330
북한주민의 직접 사용 · 관리	325
분리된 상속재산의 관리	200
분할의 당사자	111
분할의 대상인 상속재산	112
분할청구권자	111
분할의 방법	113
불균분상속	5
불통일법국	298
비밀증서에 의한 유언	240

ㅇ

사망상속	3
사망퇴직금	82
사인행위	250
4촌 이내의 방계혈족	60
사회질서에 반하는 외국법	296
사후양자	15
상속개시의 시기	50
상속개시의 장소	51
상속결격의 효과	76
상속권의 의의	6
상속능력	72
상속등기	10
상속등기 후의 소유권경정등기	182
상속등기의 중간생략등기 가부	333
상속법의 특징	7
상속분	32, 91
상속분의 결정	92

상속분의 균등화	8
상속분의 양도	106
상속분의 양수	107
상속분의 의의	91
상속에 관한 비용	52
상속을 증명하는 정보	173
상속의 개시원인	44
상속의 결격	73
상속의 준거법	290
상속의 포기	153
상속의 형태	3
상속인에 의한 등기	216
상속인에 의한 소유권보존등기	158
상속인에 의한	
소유권보존등기절차	159
상속인의 관리의무	200
상속인의 부존재	203
상속인의 부존재로 인한 등기	206
상속인의 순위	53
상속인의 자격	72
상속재산공유의 성질	87
상속재산반환의 청구	321
상속재산분리의 등기절차	202
상속재산분리의 절차	197
상속재산분리의 효과	199
상속재산분할의 효과	123
상속재산의 관리	150, 204
상속재산의 국가귀속	211
상속재산의 국가귀속으로 인한	
이전등기절차	212
상속재산의 범위	79

상속재산의 분리	197
상속재산의 분할	109
상속재산의 분할을 증명하는 정보	181
상속재산의 청산절차	205
상속준거법	291, 300
상속준거법의 관련 사항	295
상속포기의 방식	154
상속포기의 효과	155
상속회복의 청구	323
상속회복청구권	126
상속회복청구권의 소멸	133
상속회복청구권의 행사	128
생전상속	3
수증자	11, 251
수탁자가 사망한 경우	337
승인 또는 포기의 기간	137
승인 또는 포기의 무효	142
승인 또는 포기의 성질	136
승인 또는 포기의 취소	140
신분상속	3
실종선고	46
실종선고로 인한 소유권이전등기	188

○

외국인 또는 재외국민의 유언방식	243
외국인의 상속등기절차	315
양가	59
영국	311
유류분	192
유류분권	191

- 유류분권리자191
- 유류분반환으로 인한
 - 소유권이전등기190
- 유류분반환청구권193
- 유류분반환청구권의 소멸195
- 유류분산정의 기초재산192
- 유류분의 범위191
- 유류분의 산정192
- 유류분제도10, 190
- 유언능력229
- 유언능력자229
- 유언사항 법정주의229
- 유언상속4
- 유언의 개봉266
- 유언의 검인265
- 유언의 방식230
- 유언의 법적 성질227
- 유언의 무효와 취소249
- 유언의 요식성230
- 유언의 집행265
- 유언의 철회244
- 유언의 효력발생시기246
- 유언집행의 준비절차265
- 유언집행자266
- 유언집행자가 선정된 경우의
 - 등기신청274
- 유언집행자의 결격269
- 유언집행자의 결정267
- 유언집행자의 임무269
- 유언집행자의 임무종료270
- 유언집행자의 지위267

유언철회의 방식	244
유언철회의 자유	228
유언철회의 효과	246
유증	250
유증과 가등기	287
유증으로 인한 소유권이전등기	271
유증을 받는 자	251
유증의 당사자	251
유증의 목적물이 부동산의 특정 일부인 경우	279
유증의 목적부동산이 미등기인 경우	277
유증의 물상대위성	258
유증의 의의	250
유증의 종류	250
유증의무자	252
유증의무자의 담보책임	258
유증의무자의 비용상환청구권	257
이성동복	60
이종국적	297
인정사망	45
일본	300
일신전속권	62

天

자유유증주의	2
자필증서에 의한 유언	232
재대습상속	69
재산관리인	200
재산관리인의 선임	324

재산관리인의 인감증명	330
재산분여의 요건	209
재산분여의 효과	210
재산분할청구권	81
재산상속	3
재산상속의 원인	18
재산상속의 의의	16
재산의 분재	33
재협의에 의한 경정등기	187
적모서자	36
절가된 유산의 귀속	31
정지조건설	57
제사용 재산의 승계	213
제사용 재산의 승계에 의한 등기	213
제사주재자	85
제적등·초본 등을 발급받을 수 없는 경우	175
주소를 증명하는 정보	178, 318
중국	305
중혼	62
지정상속분	92
지정유언집행자	267
직계비속	53
직계존속	58
진정상속인	126
집합권리설	127

ㄷ

참칭상속인	129
채권·채무의 공동상속	88

청산형 유증	287
청산형 유증과 등기	387
출가녀	71
친가복적	68
친양자	54
친양자입양관계증명서	173

ㅋ

캐나다	312
-----	-----

ㆁ

타가	20
특별대리인	119
특별수익자	97
특별수익자의 상속분	96
특별연고자	10, 208
특별연고자에 대한 재산분여	208
특별연고자에 대한 재산분여로 인한 이전등기절차	210
특정적 유증	255
특정적 유증의 승인과 포기	260
특정적 유증의 의의	255
특정적 유증의 효과	256

ㅌ

파양	16
판결에 의한 등기와 승계집행문	338
폐가	18

포괄승계	78
포괄적 수증자	97, 253
포괄적 수증자와 상속인의 비교	255
포괄적 유증	252
포괄적 유증의 의의	252
포괄적 유증의 효과	253
프랑스	313
피상속인	6
피상속인의 본국법	291
피후견인	120

중

한정승인	148
한정승인에 의한 청산절차	151
해제조건설	57
협의분할	114
형망제급	20
형제자매	59
호주	14
호주상속	14
호주상속개시 원인	14
호주상속에 따른 재산상속	19
호주승계	7
호주승계인	8
호주승계제도	3
호주의 경질	18
호주제도	3
혼외자	15
후견인	119

판	권
소	유

상속등기실무

2012년 8월 인 쇄

2012년 8월 발 행

발행	법	원	행	정	처
인쇄	아	텍	디	자	인

〈비 매 품〉